刑法05 筆記：客觀歸責理論（二）風險實現與構成要件效力範圍

來源：刑法05 課程字幕 01:50:00 ~ 02:45:41

🕮 法條原文速查

§271（殺人罪）
I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
II：前項之未遂犯罰之。

§284（過失傷害罪）
因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。
→ 建議查閱最新條文

§276（過失致死罪）
因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。
→ 建議查閱最新條文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「常態關聯性與相當因果關係的相當性有何關係？」	**本質相同**，都是剔除顯然超出一般人經驗預期的反常因果歷程
「醫院案/救護車案中，行為人對死亡結果是否可歸責？」	**不可歸責**（風險未實現：原本是刀傷/槍傷風險→變成火災/車禍風險＝A變B）
「血友病患特殊體質案的通說見解？」	**不具常態性**＝反常因果歷程（旁觀者角度，一般人看不出血友病）→ 未遂犯
「結果的不可避免性（義務違反關聯性）是什麼？」	行為人做錯事，但就算沒做錯事結果**也會發生** → 風險未實現
「規範保護目的不相關是什麼意思？」	行為人違反的規範目的是A，但實際結果是與A**無關的B**
「被害人自我負責的前提？」	①被害人清楚知道風險 ②精神/年齡狀態正常 ③**自由地**選擇承擔
「既遂犯與未遂犯的審查順序？」	既遂犯**先客觀**（氣碎飯先客）；未遂犯**先主觀**（未碎飯先主）

一、第二層：風險實現

核心問題：行為人製造的A風險→結果發生方式是否仍基於A？還是已變成B？

子原則 1：常態關聯性

＝ 相當因果關係的「相當性」。用反面方式剔除顯然超出一般人經驗預期的反常因果歷程。

案例：醫院案/救護車車禍案

步驟	醫院案	救護車案
原本製造的風險	槍傷/刀傷致死（A風險）	刀傷致死（A風險）
實際死因	醫院火災/醫療疏失（B風險）	救護車翻車（B風險）
風險A是否實現？	**否**（A→B）	**否**（A→B）
結論	**反常因果歷程** → 不可歸責	**反常因果歷程** → 不可歸責

解題示範：救護車車禍案

老師以此案為例示範完整的刑法實例題寫作架構。

標題的五個成分

標題 ＝ ① 行為人 ＋ ② 行為 ＋ ③ 成立/不成立 ＋ ④ 罪名 ＋ ⑤ 法條依據

範例：甲持刀砍乙的行為，不成立殺人罪的既遂犯（§271 I）。

> **注意**：
>
> - 行為要**具體特定**（不能只寫「甲的行為」）
> - 罪名區分：殺人罪的**既遂犯** / 殺人罪的**未遂犯** / 殺人罪的**教唆犯** / 殺人罪的**共同正犯**
> - **不要**寫「殺人未遂罪」「教唆殺人罪」「共同殺人罪」→ 未遂、教唆、共同正犯是罪名的**實現方式**，不是罪本身

既遂犯審查順序（氣碎飯先客）

```
（一）甲持刀砍乙，不成立殺人罪既遂犯（§271 I）

   1. 客觀構成要件
      ├── 行為主體、行為、結果 → 宣稱式帶過
      ├── 條件因果關係 → 有（不砍就不會送醫）
      └── 客觀歸責
          ├── 製造法所不容許的風險 → 有
          └── 風險實現 → 無（反常因果歷程）

   → 客觀構成要件不該當（客觀不可歸責）
   → 不成立既遂犯（到此即停，不進入主觀）
```

未遂犯審查順序（未碎飯先主）

```
（二）甲成立殺人罪未遂犯（§271 II）

   1. 主觀 → 有殺人故意（不用定義什麼是故意）
   2. 客觀 → 有著手（未遂犯客觀只有著手，不會有因果歸責）
   3. 違法性、罪責 → 無阻卻事由 → 甲違法且有責

   → 成立殺人罪未遂犯
```

> **重要**：因果與歸責只出現在**既遂犯**的標題下。未遂犯的客觀只有**著手**。

子原則 1 補充：血友病患特殊體質

學說	結論	理由
通說	**不具常態性**（反常因果）	客觀歸責是**旁觀者角度**（行為當下判斷），一般人看不出被害人有血友病；不存在特殊認知
少數說（許澤天）	具常態性（可歸責）	援引民法蛋殼腦殼理論：法規範對身心特別虛弱的被害人應提供更有效保護，不應從機率角度排除

老師立場（支持通說）：

- 蛋殼腦殼理論在民法合理→肯認因果→被害人**獲得賠償**（保護被害人）
- 但在刑法→肯認歸責→行為人成立**更重的犯罪**→被害人沒有獲得任何好處
- 刑法不是為了滿足被害人的報復心

> **注意**：許澤天老師的看法**僅限**被害人「特殊體質」的情形，並非要把整個客觀歸責變成事後判斷。

子原則 2：結果的不可避免性（義務違反關聯性）

> 行為人做錯事，但就算沒做錯事，結果也還是會發生 → 風險未實現。

案例一：山羊毛案

1. 皮革工廠男員工未消毒山羊毛就交給女工加工
2. 女工感染細菌死亡
3. **事後證實**：該細菌非常頑強，即使按SOP消毒也殺不死

審查步驟	分析
行為應挑哪一段？	**交付有細菌的羊毛**（不是「沒有消毒」→ 那是義務違反，不是行為本身）
條件因果？	**有**（不交付就不會感染）
製造法所不容許的風險？	**有**（未消毒就交付）
風險實現？	**無**（就算消毒也殺不死→結果不具避免可能性）

> **過失犯行為要挑對**：不能挑「義務違反」（沒消毒）作為評價對象，否則過失犯永遠變成不作為犯。應挑「交付有細菌的羊毛」這個作為。

案例二：兒童安全座椅案

- 家長載幼童未使用安全座椅→途中落石砸死幼童
- 有安全座椅→落石一樣砸死
- 結論：結果不具避免可能性

子原則 3：規範保護目的

> 行為人違反規範，但最終結果與立法者制定該規範的目的**無關**。

案例一：德國腳踏車車燈案

- A、B晚上騎腳踏車一前一後，都沒開車燈
- 對向卡車司機甲看不到A，跨越雙黃線撞死A
- 有人主張：如果B有開車燈→B的燈會照到A→甲就會看到A→不會撞上
- 結論：B**不負責**

規範目的分析	說明
要求B開車燈的目的	**照亮自己**，讓別人不要撞到B
規範目的不是	照亮前面的A，保護A不被撞

→ 規範保護目的不相關 B不為A的死亡負責

案例二：紅線違停案（107年律師考試改編）

- 甲在紅線違停，下車離開
- 腳踏車騎士乙經過甲車旁→自己重心不穩往右摔→頭撞甲車後車廂→顱內出血死亡
- 禁止紅線停車的目的：確保往來者的**通行安全**（如閃車造成事故）
- 而非防止：有人自己摔倒頭撞到車體
- 結論：規範保護目的不相關→甲不負責

案例三：花蓮颱風人行道違停案（真實事件）

- 甲颱風天違停在人行道上
- 隔壁公寓頂樓違法磚牆被風吹倒→砸到車後座→老婆被打死
- 禁止人行道停車的目的：確保**行人安全**（行人不用與車爭道）
- 而非防止：車上乘客被墜落物砸死
- 結論：規範保護目的不相關→甲不負責

二、第三層：構成要件效力範圍

（一）被害人自我負責

> 被害人清楚知道危險、精神年齡狀態正常、**自由地**選擇承擔→ 該危險由被害人自己承擔，不歸責給行為人。

案例：

案例	說明	結論
HIV 案	女友明知男友感染HIV，仍進行無套性交	被害人自我負責
計程車案	乘客趕時間叫司機開快車，出車禍受傷	被害人自我負責
拒絕輸血案	特定教派信徒受傷後拒絕輸血致死	被害人自我負責

（二）被害人自我負責的限制

自我負責**不成立**的三種情形：

```
被害人自我負責的前提
│
├── ① 被害人身心狀態正常
│     ├── 非幼童
│     ├── 精神狀況良好
│     └── 心智無缺陷
│     → 反例：家長酒駕載幼兒→幼兒無法自我負責
│
├── ② 被害人清楚認知風險
│     → 反例：叫司機開快車，但司機未告知輪胎胎紋已磨平→乘客不知額外風險
│
└── ③ 被害人自由選擇承擔
      → 反例：被追打→闖平交道→被火車撞死→不是自由選擇
```

案例：平交道闖車（國考題）

- 行為人追打被害人→被害人前有火車、後有追打者→冒險闖平交道→被火車撞死
- 被害人闖平交道不是自由選擇，是被逼的
- 結論：**不能**自我負責，行為人仍應負責

（三）專業人員的負責

> 專業人員（消防員、警察）因執行職務死傷時，結果不歸責給原因行為人。

案例一：消防員火災殉職

- 失火→消防員前往滅火→不幸葬身火窟
- 能否歸責給失火的人？→ **不可**

理由：

1. 這些專業人員**自由選擇**該職業，且有危險津貼
2. **政策考量**：若消防員死傷歸咎失火者→失火者不敢報案求救→自己滅火→更糟糕

案例二：警察追通緝犯

- 通緝犯逃脫→警察追的過程中自己摔死
- 能否歸責給通緝犯？→ **不可**
- 專業人員的負責

三、解題實用整理

既遂犯 vs 未遂犯的審查順序口訣

類型	口訣	順序	原因
既遂犯	「氣碎飯先客」	先客觀、後主觀	刑法罰的是壞行為（客觀），不是壞想法
未遂犯	「未碎飯先主」	先主觀、後客觀	客觀上沒有實現→先討論客觀無意義→先看主觀有無故意

反常因果歷程案件的結論模式

```
1. 既遂犯標題（結論：不成立）
   → 客觀：有因果、有製造風險、但風險未實現（反常因果）
   → 客觀不可歸責 → 不成立既遂犯

2. 未遂犯標題（結論：成立）
   → 主觀：有故意
   → 客觀：有著手
   → 違法且有責 → 成立未遂犯
```

寫題注意事項

1. 標題要**具體特定行為**（不能只寫「甲的行為」）
2. 顯然無爭議的要件→**一句話帶過**（「甲違法且有責」）
3. **不要抄法條**到考卷上（刑法考點通常不是法條本身）
4. 法條引用寫**阿拉伯數字**（不要寫國字）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§271 I	殺人罪（既遂）	解題示範的核心罪名
§271 II	殺人罪（未遂）	反常因果→改論未遂
§276	過失致死罪	山羊毛案、違停案等過失犯討論
§284	過失傷害罪	天燈案等過失犯討論

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
107年律師考試題目	紅線違停＋騎士自摔撞車→規範保護目的不相關